

1020951-26.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 6ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... LTDA, alegando ter sido vítima de roubo no dia 17/10/2021, sendo-lhe subtraído cartão bancário e aparelho celular. Afirmou ter registrado a ocorrência junto à autoridade policial, solicitando o bloqueio do aparelho. Declarou que ao se deslocar às agências bancárias no dia seguinte, verificou não ter a corré Apple bloqueado o aparelho conforme fora solicitado, permitindo o uso para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

6ª Vara Cível

Avenida das Nações Unidas, 22939, São Paulo - SP - cep 04795-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1020951-26.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1020951-26.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Yago Pereira da Cruz Reis

Requerido:

Banco Santander (Brasil) S/A e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ

Vistos.

YAGO PEREIRA DA CRUZ REIS ajuizou a presente ação de conhecimento em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ITAU UNIBANCO S/A, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, BANCO PAN S/A e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, alegando ter sido vítima de roubo no dia 17/10/2021, sendo-lhe subtraído cartão bancário e aparelho celular. Afirmou ter registrado a ocorrência junto à autoridade policial, solicitando o bloqueio do aparelho. Declarou que ao se deslocar às agências bancárias no dia seguinte, verificou não ter a corré Apple bloqueado o aparelho conforme fora solicitado, permitindo o uso para vários golpes bancários. Apontou que as transações bancárias fogem ao seu perfil. Informou ter havido apenas um estorno e um cancelamento de empréstimo. Trouxe o crédito do valor de R\$ 3.377,71, que veio a saber se tratava de indenização por seguro contratado pelos golpistas, declarando o corréu que poderia ser utilizado para amenizar prejuízos, contudo, houve o estorno posterior, levando a conta a saldo negativo. Disse estar o débito decorrente do empréstimo inscrito em cadastro desabonador. Aduziu ter tentado suicídio diante do quadro desesperador que se formou, sendo internado em hospital com reembolso por coparticipação, pretendendo a restituição do valor gasto. Requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos e transações efetivadas no dia 18/10/2021, repetição do

indébito de R\$ 9.902,29 e indenização pelos danos morais de R\$ 50.000,00.

Tutela provisória a fls. 189 para "suspender a exigibilidade de todo e qualquer débito/parcela vencido(a) ou vincendo(a) referente a empréstimos contratados em nome do autor nos dias 17-18 de outubro de 2021, até final decisão, devendo as instituições financeiras requeridas se abster de descontos em conta corrente ou salário, cobranças, protestos e negativas, sob pena de crime de desobediência e multa a ser arbitrada".

Em contestação a fls. 206/225, a corré Apple arguiu sua ilegitimidade. No mérito, discorreu acerca dos sistemas de segurança implantado nos aparelhos colocados no mercado. Afirmou ter o autor deixado de adotar os procedimentos de segurança recomendados por ela em casos de perda, furto ou roubo, cabendo a ele tomar os cuidados para proteger seus dados. Apontou a inexistência de danos morais, notadamente pela informação de fls. 167, dando conta de que o autor já tentara o suicídio em outras oportunidades anteriores aos fatos ora discutidos.

O corréu Banco Itaú, em contestação a fls. 256/274, afirmou não ter sido procurando antes da citação judicial, não tendo interesse em prolongar o litígio, inibindo as cobranças e retirando a anotação do débito, não obtendo êxito na formulação de acordo com o autor, e negando os danos morais.

Em contestação a fls. 296/310, o Banco Pan alegou regularidade da transação efetuada mediante uso de "login" e senha, sendo do autor a responsabilidade pela guarda de tais dados, não respondendo por fortuito externo. Afirmou alertar seus clientes constantemente acerca das fraudes e golpes e cuidados devidos com acesso a comunicações de recebidas de terceiros entre outras possíveis fraudes, sendo impossível cancelar a operação efetivada mediante a modalidade Pix.

O Banco Santander, em contestação a fls. 442/466, alegou a regularidade das operações realizadas mediante autenticação via ID Santander e múltiplas validações do telefone habilitado. Aduziu que as operações questionadas foram feitas através do mesmo aparelho e usuário de operações anteriores não contestadas. Apontou que parte dos valores foi remetida a contas de mesma titularidade. Trouxe o ressarcimento do valor de R\$ 2.600,00, transferido para terceiro, por mera liberalidade, bem como o cancelamento do empréstimo, dispondo que o autor deve buscar das demais instituições os valores das transferências de mesmo titular.

Por fim, o corréu Mercado Pago, em contestação a fls. 588/610, dispôs que o ressarcimento do autor deve ser buscado de quem se beneficiou da transação. Negou tenha havido falha no sistema, sendo as operações realizadas do aparelho do autor. Arguiu sua ilegitimidade e a incompetência do Juízo. Aduziu ser do Estado a responsabilidade pela segurança pública. Declarou não haver perfil a ser observado, visto que a conta não era utilizada, sendo o prejuízo decorrente de fortuito externo.

Informado acordo entre o autor e o corréu Banco Itaú a fls. 688/690, restou homologado a fls. 691.

A corré Apple pugnou pelo julgamento antecipado a fls. 697.

Réplica a fls. 698/714, arrolando testemunhas a fls. 713.

Mercado Pago requereu o julgamento no estado a fls. 715/720.

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A inicial delimita a sentença e deve ser interpretada em seu conjunto associada à boa-fé. Nesse sentido, deduz-se que o autor teria sofrido roubo, perdendo a posse de cartão bancário e aparelho celular, estes usados para transações bancárias indevidas de valores, mesmo tendo comunicado a fabricante do aparelho a fim de impedir seu uso. Diante de tantas dívidas e descaso dos réus em solucionar o conflito, entendeu ter sofridos danos morais.

Rejeita-se a preliminar de incompetência. Entende a arguinte caber à Justiça Criminal o conhecimento da conduta delitiva. Ocorre que a pretensão aqui debatida é o prejuízo financeiro e moral havido pelo autor pela conduta dos réus. Não se discute o "iter criminis", concurso, autoria ou materialidade do roubo ou qualquer ação típica relacionada à persecução penal, estes sim de competência especializada. Sequer há necessidade de suspensão na forma do art. 313, inc. V, do Código de Processo Civil, pois a conduta dos réus é independente da dos autores do delito.

Já os pressupostos processuais são analisados segundo afirmado em inicial, sem se aprofundar na análise do mérito, o que se fará em cognição exauriente; assim, em tese, a parte pode retirar o Poder Judiciário de sua inércia. Determinar se o pedido é procedente ou improcedente, isto é, se o direito material lhe socorre ou não, é questão a ser analisada após a produção das provas imprescindíveis à solução da demanda.

Nesse sentido, alega o autor ter sofrido roubo, perdendo a posse de cartão e aparelho celular, estes usados por terceiros para aquisição de produtos bancários e transferências indevidas de valores, mesmo tendo comunicado a fabricante do aparelho a fim de impedir seu uso.

Resta claro, portanto, a legitimidade de todos os apontados, segundo o exame em "status assertionis", para indenização do consumidor.

Reconhecer a ilegitimidade das instituições financeiras e direcionar o autor a buscar o ressarcimento junto aos criminosos e partícipes seria dar-lhe o risco da atividade do réus, o que viola o Código de Defesa do Consumidor, entre outras legislações. Demais disso, sequer se abrangeria o quanto relatado a título de consequências morais das condutas dos réus, beirando a má-fé tal justificativa.

Nesse sentido: "Agravado de instrumento. Ação declaratória c.c. indenização. Fraude em leilão de veículo. A legitimidade ad causam deve ser examinada sob o prisma da teoria da asserção. Assim, se houver identificação entre os titulares dos direitos e obrigações, partindo da suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial, é legitimado passivo aquele que, em tese, realizou ou contribuiu para a ocorrência da fraude alegada pelo requerente. Constatada a legitimidade passiva das correções. Recurso provido" (TJSP; Agravado de Instrumento 2213056-53.2021.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2021; Data de Registro: 06/12/2021).

No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

Não há qualquer indício de que tenha o autor buscado o bloqueio do aparelho junto à fabricante. A inicial não traz nenhum número de protocolo ou captura de tela acerca de tal afirmação, gerando a improcedência do pedido em relação à correção Apple pela ausência de provas de sua conduta omissiva ou falha de seu produto capaz de contribuir para o prejuízo nos eventos. Não há como responsabilizar a correção pela falha em seu sistema se não há provas de que ele foi acionado. A inversão do ônus da prova exige um mínimo de começo de prova.

Ademais, é sabido que os aparelhos do tipo Iphone possuem funcionalidade de bloqueio e "reset" à distância, ao alcance do usuário mediante uso de sua senha pessoal em qualquer computador ou celular com acesso à internet, sem necessidade de registro de boletim de ocorrência ou interferência policial.

Prosseguindo, registre-se que parte dos débitos impugnados foi solucionado pelos réus, havendo os estornos e compensações parciais.

Em primeiro lugar, observe-se que o dever de guarda do acesso eletrônico é do usuário, e não da instituição financeira, e que o fato criminoso ocorreu fora das dependências bancárias, o que caracterizaria fortuito externo. Contudo, no caso concreto, houve nítida falha de segurança no sistema bancário de controle das transações.

As operações questionadas destoam claramente do perfil de gastos reportado nos autos.

Vejamos.

O corréu Mercado Pago afirma que não pôde estabelecer o perfil pela ausência de uso pelo autor. Ora, a movimentação de recebimento de valor não irrisório em conta sem movimentação seguida quase que instantaneamente de reencaminhamento a terceiro, por si só, deveria gerar suspeita do sistema de controle de fraudes. Não trouxe o corréu qualquer justificativa para a conduta de passagem instantânea de valores. O autor afirmou não saber que era obrigado a manter tal conta apenas por estar cadastrado na plataforma Mercado Livre.

O réu Banco Itaú praticou conduta equivalente a reconhecer o pedido quanto à declaração de inexigibilidade dos débitos, impugnando apenas o pedido de indenização pelos danos morais, firmando acordo já homologado após a contestação.

Enquanto que o Banco Santander entendeu que são inexigíveis apenas os valores remetidos a terceiros, negando-se a estornar as transferências à conta de mesma titularidade. Ressalte-se que o autor não nega que as transferências tenham sido efetivadas por seu aparelho celular previamente cadastrado, o que esvazia a contestação. O autor alega transações realizadas por terceiros fora do seu perfil com seu aparelho de acesso subtraído em conduta criminosa.

Afirmou-se ainda que a autenticação e confirmação por remessa de mensagem de texto do tipo SMS – Short Message Service, seria suficiente para garantir a efetividade do controle bancário. Contudo, é notório desde os crescentes casos de fraude por "Sim Swap" (situação em o controle da linha telefônica é tomado pelo fraudador), que tal sistema de confirmação é o mais frágil dentre todas as possíveis garantias de transações eletrônicas, justamente porque, em casos como o dos autos, a confirmação de segurança é entregue ao próprio fraudador que está na posse direta do aparelho receptor.

O corréu Santander reconheceu a nulidade do empréstimo, estornando o valor do crédito da operação, não reconhecendo a diluição desses valores pela transferências de mesma titularidade, gerando um débito indevido em nome do autor, o qual foi registrado em banco público de devedores.

A própria posição de estornar o crédito mas não a sua diluição é contraditória. Não há sentido técnico nesse proceder porque não é verossímil que fraudadores tenham efetuado empréstimo em nome do autor e o próprio autor tenha se beneficiado do crédito, transferindo tais valores para suas outras contas, e em seguida para terceiros desconhecidos.

Registre-se que o Banco Pan apenas apontou a responsabilidade do autor pela guarda das informações de "login" e senha e regularidade das operações, havendo alertas constantes a seus clientes acerca dos riscos de golpes.

Nesse cenário, as autorizações foram nitidamente temerárias, em evidente falha de segurança, cada uma delas garantindo a sequencia das demais até que os valores estivessem nas mãos dos fraudadores, lesando o autor.

Assim, nesse caso, tem os réus a responsabilidade de ressarcir a parte autora dos prejuízos materiais suportados pela falha do serviço, sendo inexigível o débito oriundo do empréstimo, seus encargos e todas as operações dele decorrentes.

O autor deve ser ressarcido de todas as operações impugnadas ainda não estornadas, inclusive encargos decorrentes do não pagamento das parcelas contratadas e repetição dos valores descontados, devidamente atualizados, para o retorno ao estado anterior, o que será demonstrado em cumprimento de sentença.

Cabe aos réus, em ação própria, querendo, buscar diante dos beneficiários das transações indevidas a sua restituição.

Quanto ao dano moral sofrido, duas são as hipóteses.

No primeiro caso, acerca das consequenciais psicossociais sofridas, ficou demonstrado pelo prontuário médico do autor que os transtornos por ele sofridos vêm de longa data, já havendo prévia tentativa de suicídio, verificando-se que nenhuma das condutas relatadas já não se esperava desse tipo de inadimplemento contratual, não havendo agravo da situação pela conduta dos réus.

Há registro de que o autor abandonou tratamento psicológico antes dos fatos que deram ensejo ao presente procedimento. Não pode se beneficiar de sua conduta autolesiva. Demais disso, o autor não é leigo na seara médica, empregado como técnico em enfermagem, presume-se ter conhecimentos das consequências gravosas causadas pelo injustificado abandono de tratamento.

Por fim, não há qualquer prova do nexo entre a tentativa de suicídio e os fatos objeto desta lide.

O segundo ponto trata-se da inscrição indevida do débito. Não se trata aqui de imprimir grande discussão acerca de "sofrimento da alma" ou angústias. Basta, para restar configurado o dano moral, o constrangimento pelo qual o autor passou ao ter seu nome ligado a rol de maus pagadores, atribuindo-se a ele, e tornando pública, a falsa pecha de mau pagador.

A negativação do nome do autor restou comprovada. Ainda que as pendências financeiras já tenham sido retiradas, não há como negar o dano moral. De fato, entende a jurisprudência que o dano moral no caso de negativações indevidas se dá

"in re ipsa", prescindido de prova do efetivo dano.

A despeito de tratar de protesto, o seguinte julgado do E. Superior Tribunal de Justiça ilustra caso semelhante a este: "O protesto indevido de título gera direito à indenização por dano moral, independentemente de prova objetiva do abalo à honra e reputação sofrido pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento respectivo" (STJ - 4ª T, REsp 312.597, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 16.04.02, DJU 24.06.02 e RT 806/149).

Quanto à fixação do valor da indenização recorro à lição do Desembargador Rui Stoco, a nos ensinar que "é na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra adequada pertinência e transita com maior desenvoltura" ("Tratado de Responsabilidade Civil", RT, 6ª edição, p. 1.707), cabendo, assim, para arbitramento da indenização, uma estimativa prudencial do julgador.

Como parâmetro de fixação da indenização devemos levar em conta que o valor deve ser tal que seja sentido como uma sanção ao causador do dano; mas também não deve propiciar um enriquecimento (sem causa) da parte lesada.

No caso dos autos, afigura-se justa e suficiente indenização no valor R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), já que não incrementa o patrimônio da parte requerente e, ao mesmo tempo, configura-se sanção à parte requerida ante o caso em concreto.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado em relação à Apple Computer Brasil Ltda. Arca o autor com as custas e despesas processuais, bem como honorários do procurador do réu APPLE, fixados em 10% do valor corrigido da causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

E, confirmando a tutela provisória, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado em relação ao Banco Santander S/A, Banco Pan S/A e Mercado Pago Ltda, para

(1) declarar inexigíveis os débitos relativos às operações realizadas fraudulentamente no dia 17 e 18 de janeiro de 2022, apontadas na inicial, condenando os réus ao estorno e ressarcimento dos valores creditados e debitados pela respectivas operações indevidas, bem como seus eventuais encargos e parcelas de resgate eventualmente pagas. Eventual saldo a ser devolvido ao autor será corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso, e acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

(2) condenar o Banco Santander ao pagamento da indenização pelos danos morais causados pela inscrição indevida do débito oriundo das operações contestadas, em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que será corrigido pela Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros de 1% ao mês a partir desta data.

Sucumbentes na quase totalidade dos pedidos, arcam os requeridos condenados com as custas e despesas processuais, bem como honorários do procurador do autor, ora arbitrados em R\$ 2.000,00.

P.I.C.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA